

1501227-23.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... M.P entendeu que deve ser aplicado o tráfico privilegiado aos réus Deivid e Rodolfo, apesar da quantidade de drogas, diante da primariedade.

Há que se considerar que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501227-23.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501227-23.2022.8.26.0537 Controle nº 912/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO DE BRITO MOTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

DEIVID DIAS MACIEL DOS SANTOS, RODRIGO RODRIGUES DA SILVA e RODOLFO DE BRITO MOTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 09 de junho de 2022, por volta das 18:45 horas, na Rodovia dos Imigrantes, altura do Km 15, Bairro Jardim Campanário, previamente ajustados e com identidade de propósitos entre si e com um quarto homem não identificado, adquiriram, guardaram e transportaram, para entrega a consumo de terceiros, cocaína (com peso total aproximado de 09 kg), droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisão preventiva dos réus na audiência de custódia (fls. 76/80), tendo sido reapreciadas por em 06.09.22 e mantidas (fls. 240).

Foram apresentadas defesas prévias (fls. 224/232 - réus Rodolfo e Rodrigo; fls. 260/266 - réu Deivid), sendo recebida a denúncia em 29.09.22 (fls. 276/277). Na

instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto às faltantes. Os réus foram interrogados no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela grande quantidade de droga, aplicando-se a redução do art. 33, § 4.º (exceto para Rodrigo que é reincidente), fixação de regime menos gravoso e perda do veículo.

O defensor dos acusados requereu a absolvição de Rodrigo e Rodolfo, posto que foram apenas para ajudar o corréu Deivid por serem amigos. Os réus são "mulas", pelo que cabível a aplicação da redução do art. 33, § 4.º para os três réus e fixação de regime aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial, os acusados confessaram a prática do crime (fls. 05, 14 e 24). O réu Deivid, na fase extrajudicial (fls. 05), disse que mora na região central de São Paulo, é vendedor autônomo e possui vício em jogo. Relatou que contraiu uma alta dívida em razão do vício e que durante uma das jogatinas, um homem desconhecido, sabendo que estava "enforcado" (sic), apresentou uma proposta de entrega de drogas na região de Diadema, pela qual receberia R\$ 3.000,00. Afirmou que aceitou a proposta, mas se sentiu inseguro para fazer a entrega sozinho. Então, contratou seus amigos, ora acusados, Rodrigo e Rodolfo, para auxiliá-lo, ficando acertado que após a entrega dividiriam o valor, recebendo cada um R\$ 1.000,00. Informou que a droga que transportavam estava sendo comercializada por, aproximadamente, R\$ 200.000,00. Narrou que pegaram a droga na região central de São Paulo, de um homem desconhecido, colocaram no veículo Fiat/Uno Vivace, cor prata, de placas OPL-2241, de propriedade de Rodolfo, e seguiram para o ponto de entrega em Diadema. Falou que quando chegaram neste município desembarcaram do veículo e aguardaram por algum tempo a chegada do comprador, porém foram abordados pelos policiais e levados para a delegacia.

Em juízo, narrou que foram entregar a droga no Frango Assado. Pediu o carro emprestado para Rodolfo, mas este disse que ia junto. Falou para os corréus que ia entregar uma bolsa com drogas. Ia ganhar R\$3.000,00 e ficaria R\$1.000,00 para cada. Narrou que pegava dinheiro emprestado para jogar sinuca e estava endividado. Trabalhava como autônomo vendendo cera carnaúba. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais. Está arrependido, praticou o crime, sem pensar nas consequências. É amigo dos corréus.

O acusado Rodrigo, na fase policial (fls. 14), disse que é amigo de Deivid e Rodolfo e que todos trabalham como vendedores autônomos na região central de São Paulo. Narrou que foi convidado por Deivid para acompanhá-lo, junto com Rodolfo, em uma entrega de drogas em Diadema, pelo que receberia R\$ 1.000,00, e aceitou. Falou que pegaram a droga de um homem desconhecido na região central de São Paulo, colocaram no carro de Rodolfo e seguiram para o ponto de entrega em Diadema. Relatou que quando chegaram ao ponto de encontro, neste município, ficaram por um tempo aguardando a pessoa que iria receber as drogas, mas acabaram abordados por policiais e levados à delegacia.

Em juízo, afirmou que são amigos do réu Deivid, este falou que estava endividado e precisava entregar uma bolsa. O réu Deivid falou que havia drogas na bolsa e cada um receberia R\$1.000,00. Falou que também estava endividado, mas foi apenas para ajudar o réu Deivid. Teve um processo por violência doméstica contra a esposa. Nada tem contra os policiais.

O réu Rodolfo, na fase extrajudicial (fls. 24), disse que é vendedor autônomo na região central de São Paulo, onde também reside, assim como os acusados Deivid e Rodrigo, amigos dele. Informou que os amigos se viram endividados e que o tráfico dava dinheiro, por isso se aproximaram de um traficante e se ofereceram para vender. Falou que o traficante respondeu que "se conseguissem compradores em quantidade e em dinheiro, poderiam sim vender" (sic). Então, passaram a procurar por interessados, até que fizeram contato com um comprador e negociaram 9 tabletes de cocaína por R\$ 26.000,00 cada um, totalizando o valor de R\$ 234.000,00, sendo

que receberiam o valor de R\$ 1.000,00 por tablete vendido. Relatou que comunicaram a venda ao seu "contato no tráfico", conseguiram a liberação dos 9 tablets, colocaram no carro e seguiram até o ponto de entrega. Afirmou que chegaram ao ponto de encontro e ficaram aguardando o comprador, porém pouco tempo depois dele chegar a polícia apareceu, os abordou e conduziu para o distrito policial.

Em juízo, narrou que o réu Deivid o chamou e pediu seu carro para transportar a bolsa. Deivid falou que estava endividado e sendo ameaçado, que precisava entregar a bolsa para ganhar dinheiro. Sabia que havia coisa errada na bolsa, mas não o que continha. Estavam apenas os três no carro e ia ganhar R\$1.000,00. Não é usuário de drogas e os corréus também não. Trabalha como camelô. Nunca foi processado. Nada tem contra os policiais. O carro era dele. Sabia que havia drogas na bolsa, mas não a quantidade.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/04), disseram que durante investigações obtiveram a informação de que naquele dia seria realizada a entrega de drogas neste município, por volta das 17:00 horas, por um veículo Fiat/Uno de cor prata e placas OPL2241, que chegaria pela Rodovia dos Imigrantes. Relataram que diligenciaram até a referida rodovia e permaneceram de campana, em um ponto estratégico, de onde poderiam visualizar a passagem do veículo. Narraram que por volta das 18:30 horas viram o veículo descrito na informação e passaram a acompanhá-lo. Falaram que quando o veículo ingressou no pátio da Rede Frango Assado, os ocupantes estacionaram e desembarcaram. Estacionaram a viatura no referido local, a fim de permanecerem em campana, aguardando uma possível negociação, porém um dos homens percebeu que se tratava de uma viatura descaracterizada e se evadiu correndo, pelo que resolveram abordar os demais acusados. Afirmaram que não foi localizado nada de ilícito na posse dos réus, mas no veículo localizaram no banco traseiro, dentro de uma mala de cor marrom, 09 tablets de pasta base de cocaína. Então, efetuaram a prisão dos réus e os conduziram ao distrito policial.

Éder (policial), em juízo, informou que receberam informação anônima, constando o carro, placa e horário que iam transportar drogas para Diadema, usando o acesso da Rodovia Imigrantes. Fizeram campana por uma hora, avistaram o carro e realizaram acompanhamento com viatura descaracterizada até o Frango Assado. Desceram 4 homens do carro, um se evadiu para o mato e os réus foram abordados. No banco de trás do carro havia uma bolsa com nove barras de cocaína. O policial Fernando entrevistou os réus que confessaram para ele, enquanto isso ele fazia a revista no carro. Não conhecia os réus anteriormente. Viram 4 homens desembarcando do carro. Estavam com duas viaturas, uma descaracterizada e outra caracterizada.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Fernando, o qual acrescentou que os réus confessaram que fariam a entrega das drogas e receberiam R\$1.000,00 cada um, porque estavam endividados. As drogas (9 barras de cocaína) estavam dentro de uma mala. Não conhecia os réus anteriormente.

Márcio (testemunha do réu Deivid), afirmou que conhece o réu Deivid há 3 anos, porque é barbeiro e o mesmo frequentava seu estabelecimento. O réu Deivid vendia limpa face e sabe que o mesmo é viciado em jogo (bilhar, baralho). Não tem conhecimento que referido réu seja traficante ou usuário de drogas. Inclusive já emprestou dinheiro para o réu jogar e este lhe pagou. Não sabe se o réu estava endividado por jogo. Acha que o réu é casado e tem filhos, porque aquele um menino para cortar o cabelo.

Dione (testemunha do réu Deivid) afirmou que o réu é seu primo, é ótima pessoa, pai de família, responsável e trabalha vendendo cera Carnauba. Nunca ouviu falar que o réu seja usuário de drogas ou traficante. Informou que o réu faz apostas em jogos (sinuca, cartas). Disse que o réu joga e sempre fica devendo.

Bruna (testemunha do réu Deivid), disse que conhece o réu há 5 anos, porque é primo de seu marido. O réu é honesto, trabalhador e bom pai. Disse que o réu trabalhava vendendo cera. Tem conhecimento que o réu já ficou endividado por jogar sinuca.

Nunca ouviu comentários que o réu seja usuário de drogas ou traficante.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 46/47 - 09 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 8,828 kg - fls. 48), aliada à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuários e, ainda, considerando que os acusados confessaram que estavam transportando as drogas, depois de tê-las negociado com um comprador neste município, por vultosa quantia (cerca de R\$ 200.000,00), que os exames periciais efetuados nos celulares apreendidos apuraram inúmeras fotografias de drogas e armas (laudos de fls. 187/204) e os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, sendo certo que não teriam como adquirir tamanha quantidade de cocaína se não fossem traficantes.

Na medida em que os réus concordaram em transportar as drogas e receberiam R\$1.000,00 está caracterizado o crime, sendo irrelevante que o fizeram para ajudar o réu Deivid.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Desta forma, impõe-se a condenação dos acusados, posto que a materialidade esta provada pelo laudo de constatação (fls. 51/53) e laudo definitivo (fls. 115/117). Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados, que segundo consta dos autos os réus Deivid (F.A de fls. 307/309) e Rodolfo (F.A de fls. 315/317; possui um processo em andamento - fls. 298, que não pode ser considerado como antecedente em face do princípio do estado de inocência) são primários, enquanto o réu Rodrigo é reincidente (fls. 63 - proc. 8688-93.2017).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência do réu Rodrigo será considerada como circunstância agravante. Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para os acusados Deivid e Rodolfo em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica dos acusados. Deixo de diminuir as penas pelas confissões dos acusados, porque já foram aplicadas no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

O M.P entendeu que deve ser aplicado o tráfico privilegiado aos réus Deivid e Rodolfo, apesar da quantidade de drogas, diante da primariedade.

Há que se considerar que nos casos em que o autor do crime é considerado "mula" do tráfico, que foi contratado para transporte único, a jurisprudência do STJ e do STF é no sentido que apenas a grande quantidade de drogas, não conduz à conclusão de que integre ou se dedique a atividades criminosas, sendo possível a aplicação do benefício.

Nesse sentido: AgRg no HC 632857, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5.^a Turma do STJ, j. em 13.09.2022, publicado DJE de 16.09.2022. O entendimento da Primeira Turma do STF no julgamento do AgRg no RHC n. 138.117/MS, MINISTRA ROSA WEBER, DJe de 6/4/2021, também é nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido".

O mesmo entendimento é da 2.º Turma do STF no RHC 159494 AgR, Ministro Edson Fachin:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRANSPORTE DA DROGA NA CONDIÇÃO DE "MULA". AGENTE INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO".

Observe que no RHC 155299 AgR / MS (Relatora: Min. ROSA WEBER, Julgamento: 08/09/2020, Publicação: 10/12/2020, Primeira Turma do STF), foi mantido o tráfico privilegiado para o caso de 20 quilos de drogas, caso similar ao deste feito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. "MULA". INCIDÊNCIA DA MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGA. CONSIDERAÇÃO EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. "BIS IN IDEM". 1. A condição de "mula" do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. A quantidade da droga não pode influenciar, simultaneamente, o aumento da pena-base e a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido".

No caso em tela, os réus foram contratados para atuarem como "mulas" do tráfico, transportando razoável quantidade de drogas (fls. 46/47 - 09 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 8,828 kg - fls. 48). Há que se observar que não ficou demonstrada a habitualidade na medida em que o acusado Deivid tem 32 anos, é primário, não possui antecedentes criminais, confessou na fase extrajudicial e em juízo, alegou que praticou o crime em razão de dívidas com jogo, mas que exercia atividade remunerada (vendedor autônomo), enquanto o réu Rodolfo tem 27 anos, é primário, não possui antecedentes criminais, confessou na fase extrajudicial e em juízo, afirmando que aceitou auxiliar no transporte das drogas devido a dificuldades financeiras.

Logo, os réus Deivid e Rodolfo preenchem os requisitos para o tráfico privilegiado, posto que são primários, não ostentam antecedentes criminais, possuem ocupação lícita, demonstrando que foi um ato isolado em suas vidas e que não integram organização criminosa ou se dedicam a atividades criminosas e inclusive confessaram em juízo, demonstrando arrependimento.

Diminuo a pena de 1/6, considerando a quantidade de drogas apreendidas (fls. 46/47 - 09 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 8,828 kg - fls. 48), já que pequena quantidade nesta Comarca é inferior a 100 invólucros e enorme de toneladas, posto que são primários, não ostentam antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º).

Estabelecendo a lei a redução entre um sexto a dois terços o réu não tem direito à redução no máximo legal. Ademais, a quantidade de droga não foi considerada na

pena-base, pelo que pode ser levada em conta para aplicar o redutor. Observo que o art. 42 da Lei n.º 11.343/06 se reporta ao art. 59 do Código Penal, o qual diz respeito à fixação da pena, ou seja, individualização da pena, o que abrange toda a pena e não apenas a pena-base, pelo que obviamente pode a quantidade de droga ser considerada no redutor. Inclusive inúmeros Acórdãos confirmaram sentenças deste juízo no mesmo sentido, pelo que pode se dizer que há jurisprudência.

O regime inicial de cumprimento da pena dos réus Deivid e Rodolfo será excepcionalmente o semiaberto (art. 33, § 3.º, do Código Penal), por serem primários e não ostentarem antecedentes criminais. Inviável a fixação de regime aberto e a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena (superior a 4 anos).

Quanto ao réu Rodrigo, tendo em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base, em razão da grande quantidade de drogas (fls. 46/47 - 09 tabletes de cocaína, com peso total aproximado de 8,828 kg - fls. 48), em 6 anos e 600 dias-multa.

Compenso a reincidência e as confissões do acusado Rodrigo porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EResp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu Rodrigo não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são

cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020. O regime inicial de cumprimento da pena do réu Rodrigo será excepcionalmente o semiaberto (art. 33, § 3.º, do Código Penal), diante do montante da pena, pois apesar da reincidência (fls. 63 – proc. 8688-93.2017 – condenação com "sursis"), as circunstâncias são favoráveis e confessou na fase extrajudicial e judicial, inclusive em consonância com a Súmula 269 do STJ (permite o regime semiaberto para reincidentes). O dia-multa será à razão mínima em face de sua situação econômica. Inviável a fixação de regime aberto e a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenchem o lapso temporal para tanto (presos em 09.06.22, pelo que ainda que considerado 2/5 para o réu Rodrigo só ocorreria em 01.11.24 para os acusados Deivid e Rodolfo só ocorreria em 08.02.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência do réu Rodrigo (circunstância judicial agravante), bem como pela quantidade de drogas apreendidas com os réus, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO DEIVID DIAS MACIEL DOS SANTOS e RODOLFO DE BRITO MOTA, à pena de 4 (QUATRO) ANOS e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, e 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, e RODRIGO RODRIGUES DA SILVA, à pena de 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se acharem incursos no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29, "caput", do Código Penal.

Incabível a substituição por pena restritiva de direitos em razão do montante da pena (art. 44, inc. I, do CP).

Tendo em vista que os réus foram presos em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que é incabível qualquer benefício, inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomenda-se na prisão em que se encontram.

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Defiro o perdimento do veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, ano/modelo 2013, cor prata, de placas PL02241, apreendido (fls. 46), já periciado (fls. 291/294), posto que utilizado para o tráfico (transporte de drogas), em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06). Observo que embora esteja em nome de terceiro (fls. 152), a proprietária foi ouvida na fase policial e confirmou a venda ao acusado Rodolfo de Brito Mota (fls. 157). Oficie-se à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes – DISE Diadema comunicando que foi determinado o perdimento, cujas providências ocorrerão após o trânsito em julgado, tendo em vista a autorização de utilização do veículo concedida às fls. 213/214. Em relação aos telefones celulares apreendidos (fls. 46/47 – marca Apple, modelo Iphone 11 (A2221), de cor branca, IMEI 354003105793646; marca Apple, modelo Iphone Xr (A2105), de cor preta; marca Samsung, modelo SM (A022M/DS) de cor vermelha), os

exames periciais demonstraram que referidos aparelhos foram utilizados em proveito do tráfico (fls. 169/207), pelo que determino o perdimento em favor da União. Providencie-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à mala de cor marrom, sem marca aparente, apreendida (fls. 46) e já periciada (fls. 113/114), tendo em vista que não tem possui econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada. Transitada esta em julgado, lancem-se os nomes dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 81) e providencie-se o necessário quanto perdimento do veículo e telefones celulares em favor da União.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 18 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA